

EXAME PRÉVIO DE EDITAL
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 05-02-2025 – ESTADUAL
JULGAMENTO

=====	
Processos:	TC-023556.989.24-2 TC-024079.989.24-0 TC-024100.989.24-3 TC-024146.989.24-9 TC-024208.989.24-4 TC-024212.989.24-8 TC-024217.989.24-3 TC-024219.989.24-1 TC-024223.989.24-5 TC-024254.989.24-7 TC-024280.989.24-5
Representantes:	Leandro Flávio de Mello Vestino Sustentar Comércio de Refeições Ltda RRX Fornecimento de Refeições Ltda Nutribem Alimentação e Serviços Ltda Delta Terceirizações Ltda Juliana Rodrigues Zamboni Julia de Souza Ferreira da Costa Soares SINDIMERENDA - Sindicato das Empresas Fornecedoras de Alimentação Escolar, Merenda Escolar e Assemelhados do Estado de São Paulo. Saimon I Varela Sunny Alimentação e Serviços Ltda Denis Toledo Lopes
Representada:	Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares - CISE - Secretaria da Educação.

Assunto: Exame prévio de edital do Pregão Eletrônico nº 90035/2024, do tipo menor preço por grupo, que tem por objeto a “*prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênicas sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na rede pública estadual*”.

Responsável: Nayla Veríssimo Neves (Coordenadora).

Advogados cadastrados no e-TCESP: Murillo Alvarez Alves (OAB/SP nº 265.795), Gabriel Barioni de Alcantara e Silva (OAB/PR nº 96.174), Juliana Ferreira de Araújo (OAB/SP nº 307.943), Juliana Rodrigues Zamboni (OAB/SP nº 425.545), Julia de Souza Ferreira da Costa Soares (OAB/SP nº 492.760), Marcos Vinicius Zenun (OAB/SP nº 278.524), Saimon I Varela (OAB/SP nº 313.143), Rafael Lopes dos Santos (OAB/SP nº 253.722), Denis Toledo Lopes (OAB/SP nº 321.867)

=====

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL. COMPOSIÇÃO DO OBJETO. DESARRAZOADO NÚMERO DE UNIDADES ESCOLARES POR LOTE. REFLEXA RESTRITIVIDADE NAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. DIVERSAS IMPRECISÕES E INCONGRUÊNCIAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE MATRIZ DE RISCO. DOCUMENTO NECESSÁRIO EM CONTRATAÇÕES DE GRANDE VULTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se do **exame prévio de edital** do pregão eletrônico nº 90035/2024, elaborado pela **COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES - CISE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**, cujo objeto é a “*prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação balanceada*”

e em condições higiênicos sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na rede pública estadual”.

1.2 Apontou **LEANDRO FLÁVIO DE MELLO VESTINO** que a divisão do objeto em apenas 9 lotes, a seu ver, *“NÃO atende de modo algum aos princípios da razoabilidade, competitividade e da economicidade, uma vez que direciona, naturalmente, os enormes lotes a não mais que 5 ou 6 empresas no Brasil, infringindo, muito claramente, o princípio da competitividade”.*

Anotou que *“os lotes hoje são licitados, em sua maioria, em número de 10 escolas, o que aumenta a competição, pois permite que um número muito maior de empresas participe dos certames”.*

Argumentou que *“somente as grandes empresas (com faturamento mensal acima de R\$ 10.000.000,00 [Dez milhões de reais]) teriam condições de ser habilitadas”,* bem assim que *“a exigência mínima de 10% de Patrimônio Líquido sobre o valor para 12 meses de contratação”* para os três primeiros lotes ultrapassaria R\$ 8.000.000,00.

Sustentou, ainda, que *“após anular o pregão de número 90029/2024, que versava exatamente sobre o mesmo objeto”,* a Administração *“o republica de modo IDÊNTICO”.*

1.3 O feito foi distribuído por prevenção, em virtude de a matéria ser conexa à tratada nos processos TC-021963.989.24-9, TC-022071.989.24-8, TC-022119.989.24-2 e TC-022499.989.24-2, que abrigaram as representações formuladas por Eco & Sapore Fornecimento de Alimentos Ltda., Verde Mais Serviços de Alimentação Ltda., a ora Representante, SINDIMERENDA - Sindicato das Empresas Fornecedoras de Alimentação Escolar, Merenda Escolar e Assemelhados do Estado de São Paulo e Nutribem Alimentação e Serviços Ltda., nos quais foi proferida decisão singular declarando extintos os processos, sem exame do mérito, diante de superveniente anulação do certame pretérito.

1.4 Considerando que as questões suscitadas pelo Representante poderiam ser esclarecidas pela unidade da Secretaria, a Sra. Coordenadora foi notificada para apresentar razões de defesa que entendesse pertinentes, após o que se decidiria sobre a concessão ou não da liminar pleiteada.

1.5 Regularmente notificada, a **Representada** deixou transcorrer *in albis* o prazo para apresentar justificativas prévias.

1.6 Neste interim, compareceu **SUSTENTAR COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA.** criticando a manutenção, na nova versão editálicia, de 09 (nove) megalotes, *“cada um abrangendo em média 100 escolas, com 42 (quarenta e duas) regionais”*.

Asseverou que os aludidos lotes contêm diversas inconsistências acerca da classificação do Posto, assim como deixam de informar os horários de distribuição e quantitativos de fornecimento de lanches e refeições.

Sustentou, ainda que a *“composição de custos apresentada no Edital está ultrapassada e não representa os valores atuais do mercado, conforme demonstrado pelos valores atualizados da Convenção Coletiva de Trabalho vigente”* (grifei).

Outrossim, questionou a exigência de obtenção de Licença Sanitária, *“sem levar em conta as dificuldades enfrentadas na obtenção, principalmente quando as questões estruturais, LTA e outras são de responsabilidade da Contratante”*.

Por outro lado, ressentiu-se da falta de reserva de cotas para PCD (Pessoa com Deficiência) e para o jovem aprendiz, conforme dispõem normas vigentes.

1.7 Por sua vez, **RRX FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA.** fez coro à inadequada concentração do objeto em 09 superlotes, aduzindo que

deveriam ser divididos em itens ou lotes específicos para cada uma das 42 Regionais

Afora isso, adicionou as seguintes censuras:

- a) equívocos na planilha de composição de preços, que não leva em consideração as peculiaridades de cada região, *“como por exemplo disponibilidade de mão de obra, convenções sindicais diferentes já que também os Sindicatos são regionalizados”*;
- b) adoção da modalidade pregão em detrimento da concorrência, tendo em vista a *“complexidade do objeto e do valor estimado em R\$ 502.059.881,07 (quinhentos e dois milhões, cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e sete centavos)”*;
- c) imposição de elevado patamar na prova na qualificação técnica (30% de refeições do lote 1, o que corresponde a 2.228.052 milhões de refeição)¹; e
- d) exigência de *“comprovação de 10% do valor anual do contrato no patrimônio líquido² restringe ainda mais a competitividade e direciona o edital para grandes empresas, haja vista que a legislação indica em até 10%”;*

1.8 Insurgiu-se **NUTRIBEM ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.**, exclusivamente, contra a exigência de registro do atestado de capacidade técnica no Conselho Regional de Nutrição – CRN³, aduzindo que somente os serviços e/ou obras de engenharia demandam tal providência.

¹ Qualificação Técnica-Operacional a) A empresa melhor classificada deverá apresentar atestado(s) de bom desempenho anterior em contrato da mesma natureza e porte, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que especifiquem em seu objeto necessariamente os tipos de serviços realizados, com indicações das quantidades e prazo contratual, datas de início e término e local da prestação dos serviços; b) Entende-se por mesma natureza e porte, serviços de alimentação coletiva, compreendida como o preparo, e distribuição de alimentação escolar e/ou de alimentação para coletividades sadias ou enfermas, com alocação de mão de obra especializada nos locais de preparo e distribuição e fornecimento de demais insumos necessários ao cumprimento do objeto da licitação, que demonstrem que a empresa prestou serviços correspondentes a 30% (trinta por cento) do objeto da licitação, do “consumo médio global mensal estimado”, sendo (...)f) Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 30% (trinta por cento) do tempo de serviços similares, sendo aceito o somatório de atestados ou certidões de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os anos serem ininterruptos;

² Qualificação Econômico-Financeira (...) Patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado de 12 meses da contratação.

³ Qualificação Técnica-Operacional (...)

e) Os atestados descritos no item anterior deverão ser registrados no Conselho Regional de Nutricionistas para comprovação de aptidão para desempenho de atividades nas áreas de alimentação e nutrição, em conformidade com a Resolução CFN nº 703/2021, do Conselho Federal de Nutricionistas.

1.9 A seu turno, **DELTA TERCEIRIZAÇÕES LTDA.** acrescentou as seguintes queixas:

e) previsão de repactuação dos preços dos demais custos, decorrentes do mercado (não relativos à mão de obra): a partir da data da apresentação da proposta⁴, *“em flagrante inobservância ao que dispõe a Lei 14.133/21, em seu artigo 92, § 3º”*;

f) exigência de que a futura contratada solicite licença sanitária para cada unidade escolar⁵, porquanto *“desvirtua o objetivo inicial do certame, que não se refere à prestação de serviços em estabelecimentos de saúde”*; e

g) divisão desigual das unidades escolares nos nove lotes, a exemplo do lote 01 com 387 escolas, restringindo a ampla concorrência na licitação.

1.10 JULIANA RODRIGUES ZAMBONI asseverou ser incongruente que a minuta da nova versão do edital esteja datada em setembro de 2024⁶, *“visto que o certame fora anulado e republicado em novembro de 2024”*.

Outrossim, impugnou os seguintes tópicos:

h) previsão de repactuação dos preços dos demais custos, decorrentes do mercado (não relativos à mão de obra), a partir da data da apresentação da proposta⁷, *“em flagrante inobservância ao que dispõe a Lei 14.133/21, em seu artigo 92, § 3º”*;

⁴ CLÁUSULA SÉTIMA - REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS (art. 92, V e X)
(...)

7.2. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado: a. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir da data de início dos efeitos financeiros do acordo, convenção coletiva ou dissídio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

b. Para os demais custos, decorrentes do mercado (não relativos a mão de obra): a partir da data da apresentação da proposta.

⁵ 9.5. Solicitar emissão de LICENÇA SANITÁRIA (LS), junto ao Centro de Vigilância Sanitária (CVS), conforme disposto no artigo 15 da Portaria CVS 1/2024, no prazo de até 120 dias, após a assinatura do contrato, condicionada a disponibilização de todos os documentos necessários por parte da Contratante.

9.5.1 Em caso de demora ou ausência de documentos para solicitar a emissão da Licença Sanitária, o prazo será prorrogado a critério da Administração.

9.5.2 As licenças que trata no item 9.5 deverá ser renovada anualmente, durante a vigência do contrato, nos termos do artigo 17 da Portaria CVS nº 1/2024.

⁶ Administração Pública do Estado de São Paulo Minuta padronizada. Análise técnica: Subsecretaria de Gestão. Exame jurídico: PGE Edital de Pregão Versão atualizada em: 05/09/2024.

⁷ Vide nota 04.

- l) ausência da matriz de alocação de riscos, obrigatória em contratações de grande vulto (R\$ 502.059.881,07);
- j) divergência de datas para início da prestação dos serviços, pois menciona ser “*novembro de 2024 mesmo com a data de sessão agendada para o dia 03 de dezembro de 2024*”.

1.11 JULIA DE SOUZA FERREIRA DA COSTA SOARES questionou os seguintes pontos:

- k) desatualização do Orçamento Referencial, pois adota dissídios coletivos com vigência expirada⁸;
- l) exigência de registro do atestado de capacidade técnica no Conselho Regional de Nutrição – CRN⁹;
- m) previsão de repactuação dos preços dos demais custos, decorrentes do mercado (não relativos à mão de obra): a partir da data da apresentação da proposta¹⁰;
- n) indefinição dos cardápios e horário de prestação dos serviços¹¹, prejudicando tanto a elaboração de propostas quanto a futura execução do ajuste pelas contratadas;

⁸ 7.9.3. A fim de assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, informa-se que foi(ram) utilizado(s) o(s) seguinte(s) acordo(s), dissídio(s) ou convenção(ões) coletiva(s) de trabalho no cálculo do valor estimado pela Administração: a) SINDIMERENDA E SINDIREFEIÇÕES – CCT 2023/2024 b) SINDIMERENDA E SEERC GUARULHOS – CCT 2023/2024 c) SINDIMERENDA E SINTERCUB – CCT 2023/2024 d) SINDIMERENDA E SINTERCAMP – CCT 2023/2024 e) SINDIMERENDA E SIND. REFEIÇÕES SUZANO – CCT 2023/2024.

⁹ Vide nota 03.

¹⁰ Vide nota 04.

¹¹ 5.2. LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

(...)

5.2.2 Os serviços serão prestados de modo contínuo e em cumprimento ao calendário escolar, em todos os dias em que a unidade escolar realizar atividades pedagógicas nas quais a presença de alunos e o fornecimento de alimentação sejam necessários, bem como, em períodos de recesso/férias em cumprimento aos processos de higienização, organização, recebimento de alimentos e armazenagem.

a) O serviço será prestado nos horários estabelecidos pela contratante que deverão estar organizados dentro do horário de funcionamento da Unidade Escolar (...)

ANEXO 4 – TABELA COM A PREVISÃO DE ALIMENTOS QUE COMPÕE AS PREPARAÇÕES E VARIAÇÕES CULINÁRIAS

(...)

c) Os cardápios serão publicados pela CONTRATANTE no Diário Oficial do Estado ou outro meio de comunicação oficial, visando à divulgação junto às unidades escolares atendidas pelo serviço contratado.

d) Os cardápios, após publicação, deverão ser cumpridos em toda a sua composição pela CONTRATADA, conforme fichas técnicas de preparo e tabela de porcionamento a ser disponibilizada pela CONTRATANTE.

- o) inclusão de custos alheios à responsabilidade da contratada¹²;
- p) aglutinação indevida de serviços de merenda com reparos prediais (pintura, lâmpadas, azulejos etc.)¹³;
- q) falhas no dimensionamento da quantidade de funcionários alocados para atendimento das escolas que serão atendidas pelos serviços licitados; e
- r) ausência de previsão edilícia quanto aos critérios e índices para correção monetária e incidência de juros, em casos de atraso no pagamento por culpa do Contratante.

1.12 SINDIMERENDA - SINDICATO DAS EMPRESAS FORNECEDORAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR E ASSEMELHADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, além de questionar o curto intervalo entre a anulação e o relançamento de um novo edital, que não passou de um (1) dia, apresentou as seguintes críticas:

- s) inexistência do Plano Anual de Contratação (PAC), em desacordo com a legislação vigente;
- t) desproporcional e desarrazoada alteração do percentual exigido na prova de patrimônio líquido (de 5% para 10% do valor estimado da contratação), *“limitando possíveis participantes sem posterior elaboração de parecer jurídico referente a tal modificação, restringindo sobremaneira a competitividade no certame”*;

¹² 5.1.4 No que diz respeito ao pré-preparo, preparo, porcionamento, distribuição e eventual transporte.
(...)

d) Realizará, quando requisitado pela Administração, às suas expensas, análise microbiológica de amostras de todos os produtos que compõem o cardápio de um dia, de uma U.E definida pela nutricionista do CONTRATANTE. E potabilidade das amostras de água colhidas na U.E, em conformidade com o disposto na Lei Estadual nº 3718 de 19/01/1983 e Portaria MS nº. 2914 de 12/12/2011, para os testes abaixo relacionados: - Escherichia coli; - Coliformes totais; - Turbidez; -- Cloro residual; - PH; - Padrões organolépticos e de Potabilidade. Em laboratórios de escolha da Contratante e disponibilizadas para o gestor e fiscal do contrato da Unidade Escolar. Sempre que houver suspeita sobre a qualidade sanitária dos alimentos preparados ou não, a Contratada deverá suspender seu consumo.

¹³ ANEXO 3 RESPONSABILIDADES MANUTENÇÃO E REPAROS (COZINHA E DESPENSEA

MANUTENÇÃO E REPAROS NA COZINHA E DESPENSEA	RESPONSÁVEL
Colocar fechadura de segurança na porta da despensa	Empresa
Colocar rodapés vedantes nas portas	Empresa

(...)

- u) o Estudo Técnico Preliminar (ETP) *“apresentado é genérico e insuficiente, limitando-se a formalidades que não fundamentam devidamente as exigências contidas no edital”*;
- v) concentração indevida dos *“serviços em nove grandes lotes, o que impede a participação de empresas de menor porte, que teriam plena capacidade de executar os serviços em lotes menores”*;
- w) imprecisão acerca do que representam os *“demais insumos necessários”*¹⁴, *“que além de tratar-se de termo genérico, sem especificidade, confunde os licitantes”*
- x) ausência de justificativas técnicas para o prazo de vigência do ajuste (dezoito meses);
- y) indevida previsão de *“pagamento por número de refeições, visto tratar-se de contrato de mão de obra”*;
- z) carência de previsão de *“uma forma de indenizar as empresas caso fiquem impossibilitadas de receber de volta seus equipamentos após o término do contrato, ou ainda, na hipótese de rescisão antecipada do contrato”*;
- aa) ausência de informações relevantes para precificar os serviços de coleta e análise laboratorial dos alimentos e a eventual ampliação compulsória e imediata do quadro de pessoal; e
- bb) falta de requisição da Certidão de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Pública do Estado de São Paulo.

1.13 SAIMON I VARELA igualmente censurou a concentração de 1.495 unidades escolares em apenas 09 (nove) megalotes.

¹⁴ 1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 1.1 Objeto (...), II) fornecimento de equipamentos, utensílios de mesa e cozinha, produtos de higiene e limpeza, gás e demais insumos necessários;

Afora isso, sustentou que o *“edital prevê valores expressivos como intervalo mínimo de lances¹⁵ a refletir em ostensiva ilegalidade por cercear a disputa”*.

Questionou a falta de exigência de *“certidão emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego comprovando que a empresa proponente cumpre a cota legal de contratação de pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social”*

Outrossim, ponderou ser indevido limitar a aferição da capacidade financeira apenas pelo patrimônio líquido, sem *“prever que tal comprovação também seja feita por meio do capital social”*.

1.14 SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. concentrou sua queixa na reunião de *“43 Diretorias totalizando 1.495 escolas, divididas em apenas 9 lotes, gerando uma possível falta de competitividade diante da quantidade de escolas e as diversas diretorias que compõem os lotes”*.

1.15 Por fim, **DENIS TOLEDO LOPES** também discutiu a formação dos lotes, pois agrupa *“inúmeras escolas e cidades dentro de um único lote, o que se mostra em flagrante ofensa à competitividade do certame”*.

Por outro lado, entendeu que *“visita técnica não poderia ser facultativa, já que se trata de uma prestação de serviços contínuos que inclui, além da mão-de-obra, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados e conservação das áreas abrangidas – Cozinha e Estoque”*.

Considerou temerária a possibilidade de o pregoeiro¹⁶ consultar *“os sistemas de registros de sanções SICAF, CNEP, CNCIAI, e-sanções, CEEP,*

¹⁵ 6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de R\$ 521.000,00 (quinhentos e vinte e um mil reais) para o grupo 01, R\$ 347.000,00 (trezentos e quarenta e sete mil reais) para o grupo 02, R\$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais) para o grupo 03, R\$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais) para o grupo 04, R\$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais) para o grupo 05, R\$ 323.000,00 (trezentos e vinte e três mil reais) para o grupo 06, R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) para o grupo 07, R\$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais) para o grupo 08 e R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) para o grupo 09.

¹⁶ 7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, na

CEIS e apenados do TCE SP, visando aferir eventual sanção aplicada à licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste certame”, pois, a seu ver, “seria o mesmo que admitir que empresas suspensas de licitar com a administração pública estariam impedidas de participar”.

Asseverou que as Convenções Coletivas de Trabalho mencionadas no item 7.9.3¹⁷ “não estão mais vigentes, fato que poderá causar sérios prejuízos à administração pública, bem como, pedidos de reequilíbrio já no início do contrato, vez que o salário e benefícios a serem pagos aos trabalhadores estarão desatualizados já no início da contratação”.

Sustentou haver cláusulas contraditórias no edital¹⁸ que impedem saber “se há disponibilidade orçamentária”.

Protestou, ainda, pela ausência de definição do índice de reajuste dos preços contratados.

Entendeu indevida a previsão de pagamento por número de refeições¹⁹, visto tratar-se de contrato de mão de obra.

legislação correlata, e no item 3.6 deste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 7.1.1. Sicafe; 7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://portal.datransparencia.gov.br/sancoes/consulta>); 7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://portal.datransparencia.gov.br/sancoes/consulta>); 7.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNCIAI, do Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 7.1.5. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e Sanções (<http://www.esancoes.sp.gov.br>); 7.1.6. Cadastro Estadual de Empresas Punidas – CEEP (<http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx>); e 7.1.7. Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://www.tce.sp.gov.br/apenados>). 7.2. A consulta ao cadastro CNCIAI será realizada em nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992. 7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

¹⁷ Vide nota 08.

¹⁸ 13. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO Diante dos subsídios apresentados, entende-se pela viabilidade técnica e operacional da futura contratação considerando ser o modelo de gestão adotado pela Administração. Com relação à viabilidade financeira, esclarece-se que a contratação onerará a dotação orçamentária de 2024, no Programa de Trabalho 12.368.0815.6172.0000, Elemento 339039 Fonte 155050001 (QSE); no valor referencial total máximo de R\$ 502.059.881,07 (quinhentos e dois milhões, cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e sete centavos), dos quais R\$ 18.208.855,45 (dezoito milhões duzentos e oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) incidirá no presente exercício. Sendo assim, a despesa está adequada aos objetivos, prioridades e metas previstas para o período, não infringindo quaisquer de suas disposições. (...).

2.4 O objeto da contratação no momento, não está previsto no Plano de Contratação Anual, pois, encontra-se em elaboração para o ano de 2025.

¹⁹ PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO (...)

4. Serão pagos os serviços efetivamente prestados, de acordo com os dias de execução mensurados e os respectivos quantitativos

Apontou que, “ao analisar os links, na aba *Resumo Escalonamento*, na coluna ‘*mês previsto para início da prestação dos serviços*’, a previsão de início, para alguns postos, no mês de novembro de 2024, ainda que o certame tenha como data prevista de abertura o dia 03 de dezembro de 2024”, o que prejudica a correta formação de preços.

1.16 Ante a existência de indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi concedida liminarmente e referendada por este E. Plenário.

1.17 Notificada, a **Representada** esclareceu que a divisão em nove lotes teria sido definida pelo setor demandante e técnico, considerando a região geográfica e o término dos contratos vigentes nas Diretorias de Ensino. Aduziu haver fornecedores com capacidade técnica suficiente para atender aos lotes, que variam de 68 a 387 escolas.

Alegou que a centralização da contratação visa otimizar a administração e reduzir a complexidade operacional, permitindo uma gestão mais eficiente e coordenada.

Salientou que a proposta de centralização e alteração do ordenador de despesas foi justificada com base no Decreto nº 64.187/2019, que reorganiza a Secretaria de Estado da Educação.

Argumentou que a medida visa desonerar as Diretorias de Ensino de atividades burocráticas e de excessivas demandas administrativas, permitindo que se concentrem em atividades pedagógicas.

(...).

1.9. O serviço é enquadrado como contínuo tendo em vista que se trata de serviço com regime de dedicação exclusiva da mão de obra, que envolve procedimentos complexos e específicos e que exigem especialização para o desempenho das atividades, pormenorizado no presente Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar (ETP), sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando que a alimentação escolar é uma política pública continuada que não deve sofrer risco de interrupção com procedimentos licitatórios ou prorrogações anuais.

Destarte, arrazoou que a centralização dos contratos e a redução do número de lotes oferecem vantagens operacionais e financeiras, como ganhos de escala e negociações mais vantajosas com fornecedores.

Observou que a centralização também facilitaria o planejamento dos serviços, garantindo maior uniformidade na execução do ajuste e na qualidade da alimentação escolar em toda a rede estadual de ensino.

Aduziu que o modelo ora adotado ofereceria vantagens operacionais e financeiras, como ganhos de escala e negociações mais vantajosas com fornecedores. Nesse sentido, apontou que o preço referencial da licitação atual está 20% abaixo do preço praticado no processo descentralizado, o que evidenciaria a eficiência financeira da centralização.

Ressaltou, também, os benefícios relacionados à eficiência no planejamento e execução; o fortalecimento da fiscalização; a redução de custos operacionais e burocráticos; a otimização dos recursos públicos; a maior transparência e responsabilidade na gestão; a capacidade de ajuste contínuo; e a redução de riscos de desabastecimento e não conformidade.

Consignou que “o recebimento de nove (9) propostas na fase de precificação do certame é um indicativo claro de que existem diversas empresas aptas a participar da licitação e atender à demanda de forma eficiente, com a capacidade técnica necessária para fornecer os serviços de alimentação escolar para as 1.495 unidades escolares envolvidas”.

Quanto à questão do dimensionamento da quantidade de funcionários, assinalou que o Termo de Referência exige que a contratada mantenha um quadro de pessoal suficiente para a prestação dos serviços, com um mínimo de uma cozinheira escolar de carga horária integral (44 horas semanais) por unidade escolar. Desta forma, entendeu que, caso identificado número insuficiente de pessoal técnico e operacional durante a execução do contrato, a contratada deverá ampliar o quadro de pessoal imediatamente.

Justificou ser a exigência de Licença Sanitária necessária para assegurar condições higiênico-sanitárias adequadas na prestação dos serviços.

Além disso, mencionou que a reserva de cotas para PCD e jovem aprendiz está em conformidade com as normas vigentes e visa promover a inclusão social e a responsabilidade social das empresas contratadas.

Defendeu o uso do pregão eletrônico para o objeto posto em disputa, destacando que os órgãos do Governo do Estado de São Paulo devem utilizar modelos de editais, termos de referência e minutas padronizadas, que incluem cláusulas sobre repactuação de preços e correção monetária conforme a Lei nº 14.133/2021.

Pontuou que a alocação de riscos seria opcional, exceto em contratações de grande vulto ou regimes de contratação integrada e semi-integrada. Afirmou, no entanto, ter sido elaborado um Mapa de Risco, que consta nos autos do processo administrativo, que dispensaria a necessidade de uma matriz de alocação de riscos.

Em relação à qualificação técnica, explicou que a exigência de registro do atestado de capacidade técnica no Conselho Regional de Nutrição (CRN) é necessária para comprovar a aptidão para desempenho de atividades nas áreas de alimentação e nutrição, conforme a Resolução CFN nº 703/2021. Acrescentou que, *“historicamente nas contratações deste objeto, processadas nas Diretorias de Ensino, sempre foram exigidos a qualificação técnica neste formato, ainda com percentual de 50% e ainda com os atestados registrados no Conselho Regional de Nutricionistas para comprovação de aptidão para desempenho de atividades nas áreas de alimentação e nutrição, isso porque o objeto desta contratação envolve atuação de profissional(is) registrado(s) em conselho profissional competente, e seja necessária a comprovação de capacidade técnico-profissional nos termos do inciso I do caput do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021, neste caso, o Conselho Federal de Nutrição – CFN”*.

Asseverou competir a cada unidade escolar a definição dos horários de distribuição dos alimentos, “contudo, os períodos de distribuição ocorrem dentro do turno de atendimento da escola, sendo: escolas com dois turnos integrais: fornece 1 (um) lanche, 1 (uma) refeição e mais 1 (um) lanche em cada turno de atendimento integral; escolas integrais de turno único, fornece 1 (um) lanche, 1 (uma) refeição e mais 1 (um) lanche dentro do seu único turno de atendimento; escolas com turnos regulares, fornece 1 refeição e 1 lanche (opcional) em cada turno de atendimento, podendo ser manhã, tarde e noite ou manhã e tarde, ou manhã e noite ou tarde e noite de acordo com o funcionamento da escola e do calendário letivo”.

Sustentou a legalidade da composição do objeto, que abrange “serviços de reparos prediais, exclusivamente dos locais da prestação dos serviços (cozinha, local armazenamento e refeitório), ocasionados pelo desgaste dos serviços prestados”.

Destacou que “o objeto desta contratação consta no Plano Anual de Contratações de 2025, cadastrado no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC, nos termos do Decreto nº 67.689/2023”.

Avaliou que não deve ser confundido o fato de o serviço ser continuado com dedicação exclusiva de mão de obra com “a forma de pagamento, que neste caso, será por posto completo, de acordo com alínea ‘a’ do subitem 7.1 do Termo de Referência”.

Registrou que “a redução mínima entre os lances é adotada em observância ao Acórdão do Tribunal de Contas Estadual e o intervalo mínimo está em conformidade com o disposto no art. 57 da Lei 14.133/2021”.

Alegou ser adequado o estabelecimento de visita técnica de forma facultativa.

Informou que “a Administração Pública não pode contratar pessoa que se encontra irregular, permitindo que uma licitante possa comprovar posteriormente sua habilitação jurídica seria o mesmo que admitir, em tese, o

recebimento de proposta por uma empresa irregular. Para uma situação dessas ocorrer, bastaria que a licitante se comprometesse a apresentar a documentação cabível quando da assinatura do contrato. Não é difícil concluir que possibilitar um cenário absurdo como esse contraria frontalmente o princípio da eficiência. Dessa forma, a habilitação jurídica deve ser comprovada no momento adequado, não sendo admitido postergar a entrega da documentação pertinente”.

Ressalvou que, no item 7.10.3 da minuta de edital, foram descritas “as convenções coletivas consideradas para cálculo do valor estimado da licitação, devendo ser considerada na Proposta, durante o Certame, a CCT vigente”.

1.18 A Procuradoria da Fazenda do Estado pronunciou-se pela improcedência das impugnações.

Avaliou que a composição do certame em lotes “atende às determinações do artigo 40, V, “b” e § 3º, I, da NLLC”, ressaltando que, “embora o parcelamento seja importante na NLLC, a Administração não poderá o adotar se o agrupamento proporcionar a economia de escala, reduzir custos de gestão de contratos entre outras hipóteses”.

Reputou legítima a intenção da Administração em alterar o modelo de contratação, sublinhando ser “uma precompreensão equivocada de vantagens mercadológicas, a de que a pulverização de ofertantes resulta necessariamente na opção mais vantajosa para a Administração, por induzir maior competitividade. Isso nem sempre é verdadeiro, como, por exemplo, em atos de concentração deferidos pela autoridade concorrencial”.

Entendeu que “especular sobre vantagens competitivas do atual sistema, de pulverização de contratos para atender à rede estadual, resultaria em interferência ilícita na opção administrativa, substituindo, aí sim, a discricionariedade legal da Administração pela vontade aleatória de interessados na competição”.

Quanto aos demais questionamentos, obtemperou que a contratação em comento está prevista no Plano Anual de Contratações de 2025, bem assim que *“as alegações de que não há Estudo Técnico Preliminar está solvido com a juntada do documento no evento 41.7 do TC 24079.989.24”*.

Além disso, consignou que o Parecer Jurídico foi juntado ao processo e a Administração respondeu a todas as recomendações contidas na peça opinativa.

De igual forma, ponderou ter sido elaborado mapa de gestão de risco, que atenderia à exigência legal.

Sublinhou, também, que os termos do edital seguem o modelo do Portal Compras de São Paulo, com base nos efeitos financeiros de reajustes salariais e outros componentes de custo, conforme a NLLC. Nesse aspecto, acrescentou ter a Administração esclarecido que as bases para reajuste se referem aos efeitos financeiros das alterações salariais da categoria relevante, para a composição do preço contratual relativo à mão de obra.

Destacou que, a seu ver, as exigências de qualificação técnica e financeira foram consideradas proporcionais e justificadas, anotando que a exigência de registro no Conselho Regional de Nutricionistas é necessária para a segurança dos serviços.

Entendeu, também, adequados os esclarecimentos relacionados à licença sanitária, à indefinição do objeto, à composição do objeto, às cotas para PCD e jovem aprendiz, ao dimensionamento da quantidade de funcionários e à visita técnica facultativa.

Frisou, ainda, que *“a orçamentação não está vencida e se refere à composição de preços em cumprimento às últimas convenções trabalhistas dos sindicatos regionais. As planilhas de composição de custo levam em conta o dissídio do ano base 2024/2025”*.

1.19 O **Ministério Público de Contas** pronunciou-se pela parcial procedência das impugnações.

Destacou, inicialmente, a necessidade de que sejam incluídos, como anexo ao ETP, os estudos de viabilidade técnica e econômica que fundamentaram o edital, uma vez que o documento apresentado foi considerado "*genérico e insuficiente*". Além disso, apontou a ausência de redefinição do início da execução dos serviços, observando que a nova versão do edital, republicada em novembro, ainda faz referências ao mês de setembro, o que exige correção.

Sublinhou que a divisão do objeto em apenas nove lotes não atende aos princípios da razoabilidade, competitividade e economicidade, pois os direciona a um número muito restrito de empresas, estimado em não mais que cinco ou seis em todo o Brasil, o que infringe claramente o princípio da competitividade.

Nesse aspecto, ponderou que a reunião de um extenso rol de unidades escolares em um mesmo lote impõe aos licitantes comprovações de qualificação técnica e econômico-financeira mais elevadas, com o potencial de reduzir a disputa a um diminuto grupo de empresas.

Outrossim, avaliou que, embora a Administração tenha defendido que o preço referencial da licitação atual está 20% abaixo do preço praticado no processo descentralizado, não foram apresentados estudos, levantamentos e relatórios que comprovem a economia e a viabilidade técnica, econômica e sustentável do formato escolhido.

Anotou, ainda, a defasagem do orçamento referencial, que utilizou dissídios coletivos com vigência expirada. Nesse aspecto, inobstante a Administração tenha informado que as planilhas de composição de custo apresentaram propostas em cumprimento ao dissídio do ano base 2024/2025, o edital menciona acordos, dissídios ou convenções coletivas do período 2023/2024.

Ponderou ser necessário que a Administração assegure que as atividades a serem executadas se enquadram na relação prevista nos Anexos I ou II da Portaria CVS 1/2024 e que os custos envolvidos na obtenção da licença sanitária foram devidamente contabilizados no orçamento estimativo.

De outro modo, anotou ser improcedente a crítica à exigência de comprovação de reserva de cotas para pessoas com deficiência (PCD) e menor aprendiz, uma vez que o edital exige a declaração do licitante de que cumpre as exigências de reserva de cargos, conforme previsto na legislação vigente.

Ademais, salientou a pertinência de se revisar e aprimorar o texto editalício, incluindo a relação e classificação de unidades escolares, horários e quantitativos de lanches e refeições, dimensionamento da mão de obra e especificação dos insumos necessários.

Anotou, também, que a Administração deve incluir os estudos de viabilidade técnica e econômica como anexo ao Estudo Técnico Preliminar, bem como a matriz de alocação de riscos, e corrigir as datas de início da execução dos serviços na nova versão do edital.

De outro modo, afastou as críticas à exigência de análise microbiológica dos produtos e potabilidade da água, que considera necessária para manter a qualidade dos serviços, e à contratação conjunta dos serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos, controle de pragas e manutenção predial, eis que permitida sua subcontratação.

Igualmente, obtemperou que os critérios e índices para correção monetária e incidência de juros foram devidamente especificados no edital, bem assim que não há impropriedade no uso do pregão ou no intervalo mínimo de lances fixados.

Entendeu adequadas as cláusulas de capacidade técnica e econômico-financeira, ressaltando que a Administração poderá avaliar a pertinência de admitir ambas as mensurações econômicas e reduzir o percentual exigido.

Observou, ainda, que *“tanto a Administração Estadual quanto a PFE anunciam que já foi elaborado o Plano de Contratações Anual de 2025 e que dele participa o objeto colocado em disputa”*.

Insubsistentes, a seu ver, as críticas direcionadas ao prazo de vigência, à forma de pagamento, à falta de previsão de indenização e à visita técnica.

Salientou, ainda, que *“a falta de requisição de certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual, decorre da não incidência de tributos estaduais pertinentes ao objeto contratual, em conformidade com a jurisprudência pacificada deste Tribunal e ao disposto no art. 193 do CTN”*.

Por fim, consignou, em relação à possibilidade de consulta a cadastros de pessoas físicas ou jurídicas punidas, que *“o item 7.1 do Edital deixa claro que será verificada a ‘existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação’, a indicar que a apenada não será eliminada do torneio em razão de sanções que não se estendam à contratação pretendida. Além disso, ressaltou que o ato convocatório impugnado permite a manifestação prévia da interessada antes da decisão de desclassificação ou inabilitação (vide item 7.3.2), em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa”*.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES pretende a *“prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênicos sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na rede pública estadual”*.

No entanto, o instrumento convocatório merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação de regência e à jurisprudência desta Corte.

2.2 Entendo pertinente iniciar a análise da matéria por aspecto que constou na maior parte das representações, qual seja a composição do objeto.

De um lado, questiona-se a aglutinação indevida de serviços de preparo de merenda com reparos prediais. Sobre a matéria, necessário frisar ser assente o entendimento deste Tribunal no sentido de que, desde que possibilitada a subcontratação, como no presente certame, *“nada obsta a aglutinação de atividades relacionadas à conservação, limpeza e manutenção de equipamentos e utensílios, bem assim ao suporte logístico, (...) eis que pertinentes ao preparo de refeições”*²⁰.

2.3 De outro modo, há inúmeros argumentos contrários à concentração de 1.495 unidades escolares em nove “megalotes”, abrangendo mais de 40 unidades regionais:

Lote 1 – total de escolas licitadas: 387
Lote 2 – total de escolas licitadas: 215
Lote 3 – total de escolas licitadas: 248
Lote 4 – total de escolas licitadas: 145
Lote 5 – total de escolas licitadas: 73
Lote 6 – total de escolas licitadas: 160
Lote 7 – total de escolas licitadas: 98
Lote 8 – total de escolas licitadas: 101
Lote 9 – total de escolas licitadas: 68

Dentre as problemáticas advindas dessa composição, foi apontado que somente as grandes empresas (com faturamento mensal acima de R\$ 10.000.000,00 [Dez milhões de reais]) teriam condições de ser habilitadas, bem assim que a exigência mínima de 10% de Patrimônio Líquido sobre o valor para 12 meses de contratação para os três primeiros lotes ultrapassaria R\$ 8.000.000,00.

²⁰ TC-017689.989.19-2. Sessão Plenária de 23-10-2019. De minha relatoria.

No mesmo sentido, a qualificação técnica requerida para o lote 01, por exemplo, ainda que fixada em apenas 30%, corresponde ao preparo de 2.228.052 refeições.

Em suas justificativas, a CISE apontou, em linhas gerais, que a centralização ora pretendida, visa desonerar as diretorias de ensino, que passariam, assim, a concentrar sua atenção na atividade fim.

Defendeu, ainda, que “a concentração dos contratos em um número menor de lotes possibilita uma gestão mais ágil e coordenada, evitando a dispersão de esforços em múltiplos contratos de menor porte. Isso facilita a fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços, permitindo que a administração central tenha um controle mais efetivo sobre os contratos, sem a sobrecarga de gerenciar inúmeros processos dispersos”.

Sustentou haver melhor custo-benefício no modelo, cujo preço referencial “está 20% abaixo do preço praticado no processo descentralizado”.

Não obstante, observo que tanto as justificativas ora apresentadas pela Administração, quanto o Estudo Técnico Preliminar, são genéricos quanto aos benefícios do modelo pretendido, não demonstrando de maneira concreta a vantajosidade invocada.

Nesse sentido, entendo oportuno transcrever as ponderações trazidas pelo *Parquet* de Contas:

“No caso, há se observar que a reunião de extenso rol de unidades escolares em um mesmo lote acaba por impor aos licitantes comprovações de qualificação técnica e econômico-financeira mais elevadas, como é o caso, por exemplo, do Lote 1, que reúne 387 escolas, impondo, para fins de habilitação técnica, a comprovação de fornecimento mínimo de 2.228.052 refeições/mês e a comprovação de patrimônio líquido mínimo de R\$ 6.934.593,10 (10% do valor estimado para 12 meses), para habilitação econômico-financeira. Exigências que, por via reflexa, têm o potencial de reduzir a disputa a um diminuto grupo de empresas, em prejuízo da competição e obtenção da melhor oferta.

Nesse sentido, embora conste do Estudo Técnico Preliminar que as unidades escolares a serem atendidas pela presente contratação contam como “pelo menos 6 fornecedores distintos que já executam serviços vinculados ao mesmo objeto”, e a Pasta noticie que já recebeu

“nove (9) propostas na fase de precificação do certame”, não restou cabalmente demonstrado que tais fornecedores atendem às condições de participação de cada um dos lotes postos em disputa, ou mesmo que os lotes de maior extensão contam com a manifestação de interesse de diversos licitantes, garantindo a competitividade em todos eles.

Também não há nos autos documentação que demonstre a impossibilidade técnica ou prejuízo econômico decorrente da subdivisão dos lotes em subgrupos com menor quantidade de Diretorias de Ensino e/ou unidades escolares. Ao contrário, as justificativas trazidas pela Origem focam, em suma, nas vantagens operacionais que o modelo pretendido traria à Administração.

Ainda que se reconheça que a redução do número de lotes reduz o número de contratos a serem gerenciados pela Pasta Estadual e, eventualmente, possibilite a uniformização da prestação de serviços, para a manifestação de regularidade se faz necessário a comprovação de que a opção é a mais vantajosa economicamente. Contudo, na presente análise, não há como atestar que tal modelo seja, de fato, o mais econômico.

Apesar de a Administração defender que “o preço referencial da licitação atual está 20% abaixo do preço praticado no processo descentralizado”, não trouxe aos autos os estudos, levantamentos e relatórios produzidos ao longo do planejamento preliminar que denotem a referida economia e/ou que atestem a viabilidade técnica, econômica e sustentável do formato escolhido.

Dito isso, por força do impacto da dimensão dos lotes nas exigências de habilitação e demais condições de participação e execução dos serviços, com vistas à ampliação da competitividade do certame, tem-se necessário que a Administração reveja a composição dos lotes impugnados”. (Grifei).

Assim, considero procedentes as críticas à composição dos lotes, devendo a Administração readequá-los, de forma a “*buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado*”, nos termos do que determina o 47, II e § 1º, III da Lei nº 14.133/21²¹.

Necessário, ainda, que seja o certame precedido de consistentes estudos de viabilidade técnica e econômica dos lotes que vierem a ser licitados.

²¹ Art. 47. As licitações de serviços atenderão aos princípios:

(...)

II - do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso.

§ 1º Na aplicação do princípio do parcelamento deverão ser considerados:

(...)

III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

2.3 Outrossim, diversas imprecisões e omissões no edital foram apontadas nas iniciais e confirmadas pelo MPC, *“sobretudo a relação e classificação de unidades escolares; os horários e quantitativos de lanches e refeições a serem distribuídos; o dimensionamento da mão de obra a ser contratada, evitando-se, inclusive, a necessidade de ampliação imediata do quadro de pessoal; e, a especificação dos insumos necessários à execução do ajuste”*.

2.4 Esse cenário, aliás, denota a procedência da queixa quanto à insuficiência e generalidade do Estudo Técnico Preliminar, já mencionada também no item 2.2 deste voto.

Acolho, por tais razões, a recomendação do Ministério Público de Contas para que *“a Administração avalie a pertinência de incluir, como anexo ao referido documento, os estudos de viabilidade técnica e econômica que o balizaram”*.

2.5 De outro modo, afasto a crítica à defasagem orçamentária, eis que esclarecido pela Administração terem sido utilizadas as últimas convenções trabalhistas dos sindicatos regionais, mencionadas no subitem 7.9.3 do edital, válidas no momento da elaboração do orçamento.

Não obstante, tendo em vista que muitas das convenções citadas já possuem versões atualizadas, necessário que seja o orçamento readequado à realidade das tratativas vigentes.

2.6 Além disso, a suscitada inadequação na planilha de composição de custos mostra-se genérica, não tendo sido apresentado pela empresa RRX

Refeições o impacto das peculiaridades por ela mencionadas nos montantes orçados.

2.7 Insubistentes, ainda, as queixas direcionadas à forma de pagamento, pois, ao contrário do alegado nas iniciais, o edital é claro ao dispor que *“a unidade de medida utilizada para padronização das contratações (...) é o ‘Posto/Mês’ efetivamente coberto”*, sendo que *“cada unidade escolar é considerada com um posto de serviço”* (subitem 7.1.a).

2.8 Na linha do parecer do MPC, *“não se verifica a suscitada ausência de exigência de comprovação de reserva de cotas para PCD e Menor Aprendiz, vez que a requisição de declaração do licitante, no cadastramento da proposta inicial, de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social (item 4.3.4 do Edital) atende ao previsto no art. 63, IV, da Lei nº 14.133/21. Além disso, o edital exige o cumprimento de reserva de cargos e contratação de jovem aprendiz ao longo da execução do objeto (6.44 do Anexo I – Termo de Referência e cláusula 9 da Minuta de Termo de Contratual), em consonância com o art. 116 da Lei nº 14.133/21”*.

2.9 Igualmente, mostra-se adequado que o edital não imponha a demonstração de regularidade fiscal perante a Fazenda Pública do Estado, pois o objeto abrange somente o preparo e distribuição de refeições, não sendo de responsabilidade da empresa contratada o fornecimento dos gêneros alimentícios²². Nesse cenário, ela apenas fornece a mão de obra para preparar

²² 1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 Objeto: Contratação de serviços de preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, que atendam aos padrões nutricionais e dispositivos legais vigentes aos alunos regularmente matriculados em unidades escolares da rede estadual de ensino (incluindo ETEC, Indígena e Quilombola) mediante o fornecimento de I) mão de obra treinada para a execução de todas as atividades de recebimento, armazenamento, higienização, pré-preparo, preparo e distribuição de alimentação, bem como higienização de equipamentos, utensílios e instalações das cozinhas e despensas das unidades escolares e para a supervisão das atividades relacionadas, II) fornecimento de equipamentos, utensílios de mesa e cozinha, produtos de higiene e limpeza, gás e demais insumos necessários e III) fornecimento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, mobiliários e utensílios utilizados, serviços de reparo e adequação das cozinhas e despensas em atendimento às normas da Vigilância

e servir aqueles alimentos, denotando assim mera prestação de serviços, sobre a qual incide apenas a tributação municipal (ISSQN).

2.10 No que tange à licença sanitária, observo que a primeira versão do edital foi ajustada, ampliando para 120 dias o prazo para sua obtenção, além de expressamente ressaltar “a disponibilização de todos os documentos necessários por parte da Contratante”²³.

Ademais, há de se destacar que a exigência de que a futura contratada solicite licença sanitária para cada unidade escolar decorre da previsão contida Portaria CVS 01/2024²⁴, que não se destina apenas à prestação de serviços em estabelecimentos de saúde, como pretende a Representante, mas também àqueles de interesse da saúde, dentre os quais encontra-se consignado na norma o fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, classificado como Nível de Risco III (Alto)²⁵.

Sanitária e serviços de controle integrado de pragas, conforme condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, de acordo com as subdivisões na forma de itens que compõem este instrumento.

1.1.1 Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

1.1.2 Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual nº 68.185, de 11 de dezembro de 2023.

1.1.3 O objeto desta contratação não se enquadra como serviços de luxo, observando o disposto no Decreto estadual nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

NOTA: O fornecimento de gêneros alimentícios é de responsabilidade exclusiva da Contratante.

²³ 5.6 Licença Sanitária Solicitar emissão de LICENÇA SANITÁRIA (LS), junto ao Centro de Vigilância Sanitária (CVS), conforme disposto no artigo 15 da Portaria CVS 1/2024, no prazo de até 120 dias, após a assinatura do contrato, condicionada a disponibilização de todos os documentos necessários por parte da Contratante.

5.6.1 Em caso de demora ou ausência de documentos de responsabilidade da Contratante, para solicitar a emissão da Licença Sanitária, o prazo será prorrogado a critério da Administração.

5.6.2 A licença que trata no item 5.6 deverá ser renovada anualmente, durante a vigência do contrato, os termos do artigo 17 da Portaria CVS nº 1/2024.

²⁴ Art. 15 A empresa fornecedora de alimentos preparados preponderantemente para terceiros (CNAE 5620-1/01), que não dispõe de instalações próprias e se utiliza das instalações do estabelecimento contratante, é denominada contratada. §1º A solicitação de LS da contratada deve ser efetuada após a celebração do contrato de prestação de serviço.

§2º A LS da contratada será emitida com seu CNPJ e razão social, e com endereço da empresa contratante.

§3º A contratada que prestar serviços em diferentes endereços deve possuir um CNPJ de filial para cada endereço onde o serviço for prestado. A LS deve ser emitida com o CNPJ da filial e com endereço da empresa contratante.

²⁵ Nível de Risco III (Alto) – Atividade sujeita ao licenciamento sanitário que exige análise documental e inspeções prévias no estabelecimento, por parte do serviço de vigilância sanitária competente (Anexo I).

2.11 No que tange à habilitação técnica, observo que o elevado quantitativo requerido decorre do modelo adotado, que concentrou o objeto em apenas 9 (nove) lotes, o que deverá ser reavaliado, como mencionado anteriormente.

De todo modo, o percentual requerido (30%), em si, encontra-se aquém do máximo estabelecido pelo artigo 67, § 2º, da Lei nº 14.133/21.

Outrossim, a exigência de que os atestados de capacidade técnica estejam registrados no Conselho Regional de Nutrição – CRN, entidade profissional competente para o objeto em disputa, tem amparo no artigo 67, inciso II, da mencionada norma. Ademais, noto que a Resolução CFN nº 703/2021²⁶ dispõe expressamente sobre a averbação de tais documentos.

2.12 A visita técnica facultativa é medida que se alinha ao que dispõe o artigo 63, §§ 2º e 3º, da Lei nº 14.133/21, os quais estabelecem sua viabilidade, desde que prevista a *“possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação”*.

2.13 No que tange à habilitação econômico-financeira, assim como já mencionado em relação à *expertise* técnica, a exorbitância do valor exigido na prova de patrimônio líquido decorre do agrupamento ora pretendido, e que deverá ser reavaliado. No entanto, o percentual requerido encontra amparo no artigo 69, § 4º, da lei de regência.

Ademais, há que se consignar entendimento deste Plenário no sentido de que *“o artigo 69, § 4º, da Lei nº 14.133/214 estabelece prerrogativa ao administrador, para que discricionariamente estabeleça se o requisito de qualificação econômica ocorrerá pela via do capital social mínimo ou pela via do patrimônio líquido. Em se tratando de matéria afeta ao juízo de conveniência e*

²⁶ https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/resolucoes/resolucoes_old/Res_703_2021.html

*oportunidade, seria inadequado censurar o emprego de apenas uma das hipóteses, consoante decidido pelo Plenário deste Tribunal nos autos dos TCs12646.989.23 e 12691.989.23*²⁷.

2.14 Não cabe censura ao questionado redutor entre lances, pois o valor mínimo estabelecido (correspondente a 0,75% de cada lote) se encontra dentro dos percentuais usualmente admitidos pela jurisprudência desta Corte, que variam “entre 0,5% a 1% do menor valor inicial obtido”, a exemplo do decidido nos autos do TC-013111.989.18-2²⁸.

2.15 Concernente à possibilidade de o pregoeiro consultar sistemas de sanções (SICAF, Cnep, CNCIAI, e-sanções, CEEP, CEIS e apenados do TCE SP), bem observou o MPC que “o item 7.1 do Edital deixa claro que será verificada a ‘existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação’, a indicar que a apenada não será eliminada do torneio em razão de sanções que não se estendam à contratação pretendida”. Além disso, consignou “que o ato convocatório impugnado permite a manifestação prévia da interessada antes da decisão de desclassificação ou inabilitação (vide item 7.3.2), em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa”.

2.16 Assim como o Órgão Ministerial, entendo que o simples fato de não ter sido incluída a presente licitação no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024, “não é capaz de, por si só, levantar suspeitas acerca da adequação orçamentária, mesmo porque os órgãos e entidades não estão proibidos de firmar contratações que não constaram do planejamento anual, se disponíveis os recursos. Seja como for, tanto a Administração Estadual quanto a PFE

²⁷ TC-008882.989.24-7. Sessão Plenária de 24-0424. Relator Conselheiro ROBSON MARINHO.

²⁸ Sessão Plenária de 18-07-2018, Relator Conselheiro Substituto ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.

anunciam que já foi elaborado o Plano de Contratações Anual de 2025 e que dele participa o objeto colocado em disputa”.

2.17 Equivocam-se as representantes em relação às cláusulas de repactuação de preços dos custos não relativos à mão de obra, pois o edital, ao estabelecer o interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação, a ser contado a partir da data da apresentação da proposta, refere-se ao prazo do artigo 135, § 3º, da Lei nº 14.133/21, hipótese que não se confunde com a data-base prevista no artigo 92, § 3º, que se vincula à data do orçamento estimado.

Além disso, ao contrário do aventado na inicial, o item 7.9 estabelece claramente que *“a respectiva variação será apurada mediante a aplicação do índice de reajustamento Índice de Preços ao Consumidor – IPC FIPE”*.

2.18 Deve, ainda, ser afastada a suscitada ausência de critérios e índices para correção monetária e incidência de juros, em caso de atraso de pagamento pela contratante, eis que devidamente especificados no item 7.4.b do Anexo I.

2.19 Tampouco vislumbro qualquer restritividade ou ilegalidade no prazo de vigência estabelecido (18 meses), remetendo-se a questão ao campo do exercício do poder discricionário do administrador.

No entanto, pertinentes as incongruências apontadas nas datas constantes na minuta da nova versão do edital (setembro/2024), no prazo de início dos serviços (novembro/2024) e no Resumo Escalonamento (novembro/2024), que não condizem com a cronologia dos fatos e devem ser corrigidas.

2.20 Ademais, a análise microbiológica de amostras do cardápio e da água colhida na unidade escolar é prática comum em serviços da espécie, não havendo que se falar serem seus custos alheios à responsabilidade da contratada.

Aliás, sobre o tema, acertadamente pontuou o MPC que “a verificação da qualidade dos materiais empregados na produção das refeições e lanches é condição imprescindível para que sejam mantidas, durante toda a execução contratual, as obrigações assumidas, em conformidade com o que dispõe o art. 92, XVI, da Lei nº 14.133/21, não podendo a contratada se furtar de tal *mister*”.

Quanto aos custos inerentes a esse serviço, não tendo sido apresentadas maiores informações pela Administração, avalio ser pertinente adverti-la que sejam eles devidamente estimados em seu orçamento referencial.

2.21 Outrossim, insubsistente a aventada necessidade de que seja prevista “uma forma de indenizar as empresas caso fiquem impossibilitadas de receber de volta seus equipamentos após o término do contrato, ou ainda, na hipótese de rescisão antecipada do contrato”. Como esclareceu a Administração, *“o fornecimento dos equipamentos, utensílios e outros são inerentes à execução dos serviços. Neste caso, caberá ao proponente incluir em sua proposta os custos desta natureza de modo a garantir a plena execução dos contratos, no período de sua vigência”*.

De mais a mais, o subitem 5.3.5.11 e seguintes do Anexo I apresentam todas as informações pertinentes ao uso e manutenção e eventual devolução de bens e equipamentos.

2.22 Em relação à matriz de risco, obrigatória em contratações de grande vulto como a que ora se examina, observa-se que a Coordenaria carrou aos autos documento denominado “*Mapa de Riscos*”, o qual, a seu ver e da PFE, cumpriria a função legal.

No entanto, o próprio Parecer Referencial CJ/SEDUC 16/2024, mencionado pela CISE, esclarece que *“ordinariamente o gerenciamento de risco se materializa por meio de um “mapa de riscos”, o que é diferente da “matriz de riscos” a que alude o artigo 6º, inciso XVII, da Lei Federal nº 14.133/2021 (cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do ajuste)”*.

Entendo que o objeto, embora vultoso, não requer matriz de risco de grande complexidade, o que não significa que possa ser ela substituída por outro documento.

Assim, com o MPC, entendo insuficiente *“a produção de mapa de gestão de riscos, que sequer foi disponibilizado às licitantes, prejudicando a elaboração de suas propostas”*.

2.23 Infundada a alegação de que deveria ser adotada a concorrência no presente certame, eis que não há, como pretende a Representante, complexidade que justifique seu uso, ao contrário, o serviço licitado é comum, enquadrando-se na definição do artigo 6ª, inciso XLI, da Lei nº 14.133/21.

2.24 Por fim, não há qualquer ilegalidade no relançamento do edital em curto espaço de tempo, o que depende da necessidade e da estrutura da Administração para o fazer.

2.25 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero parcialmente procedentes as impugnações, determinando que a Administração adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, devendo, em especial:

- a) ampliar o número de lotes licitados, com base em estudos de viabilidade técnica e econômica, em observância ao que determina o 47, II e § 1º, III, da Lei nº 14.133/21;
- b) corrigir as diversas imprecisões constantes no edital e termo de referência;

- c) aprimorar o Estudo Técnico Preliminar, nele consignando os estudos de viabilidade técnica e econômica que o balizaram;
- d) atualizar as convenções utilizadas na peça orçamentária;
- e) eliminar as incongruências apontadas nas datas constantes na minuta da nova versão do edital (setembro/2024), no prazo de início dos serviços (novembro/2024) e no Resumo Escalonamento (novembro/2024);
- f) mensurar no documento orçamentário os custos inerentes às análises microbiológicas do cardápio e da água colhidas nas unidades escolares;
- g) elaborar a matriz de risco, nos termos do que determina o artigo 6º, inciso XVII, da Lei nº 14.133/21.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório relacionados.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 05 de fevereiro de 2025.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
CONSELHEIRO